

MOHD RAZIF BIN RUSLI

LWN.

TUTY YUHAINI BINTI ABDUL HAMID

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 16 Jun 2020 bersamaan 24 Syawal 1441H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0021-2020]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Pemohon : Tn. Muhammad Asyraf Bin Abdul Halim daripada
Tetuan Mohd Irwan Bin Mohd Mubarak.**

Peguam Responden : Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pihak Pemohon pada 11/2/2020 bagi menyemak keputusan / perintah yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor pada 13/1/2020 melalui Kes Permohonan No. : 10200-038-0027-2019.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- (a) Mahkamah Yang Mulia menyemak dan / atau meminda / mengubah dan / atau membatalkan dan / atau mengeneipikan Perintah bertarikh 13/1/2020 melalui Kes Permohonan No. : 10200-038-0027-2019 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di Negeri Selangor;
- (b) Mahkamah Yang Mulia menggantung Perintah bertarikh 13/1/2020 melalui Kes Permohonan No. : 10200-038-0027-2019 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di Negeri Selangor;
- (c) Mahkamah Yang Mulia membenarkan Permohonan Interim Hadhanah melalui Kes Permohonan No. : 10200-038-0027-2019; dan
- (d) Lain-lain perintah yang difikirkan adil dan wajar oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 10/2/2020. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut -

- a) Perintah yang diputuskan oleh Mahkamah Bicara pada 13/1/2020 adalah bercanggah dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebajikan serta kemaslahatan pihak-pihak dari segi Hukum Syarak dan Undang-Undang.
- b) Wujudnya kecacatan dalam proses / prosedur Mahkamah Bicara.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden bernikah pada 9/12/2007 dan telah bercerai secara Hakam pada 18/7/2017 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam melalui kes Saman No. : 10002-055-0441-2018. Hasil perkahwinan Pemohon dan Responden, mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata iaitu anak pertama lelaki berumur 12 tahun, anak kedua perempuan berumur 10 tahun dan anak ketiga lelaki 5 tahun. Tuntutan Hak Jagaan Kekal anak-anak tersebut telah difailkan oleh Pemohon melalui Kes Saman No. 14200-028-0266-2019.

[5] Pada 11/1/2019, Pemohon telah memfailkan Permohonan Hak Jagaan Sementara Anak secara ex-parte melalui Kes Permohonan No. : 10200-038-0027-2019. Permohonan ex-parte Pemohon ini telah ditolak oleh YA Hakim Bicara semasa prosiding pada 29/1/2019 dan mengarahkan supaya permohonan tersebut didengar secara inter-parte serta salinan permohonan tersebut hendaklah diserahkan kepada Responden. Serahan kepada Responden hanya berjaya disempurnakan dibuat melalui penyampaian gantian di alamat No. 46, Jalan Amanputra, 47100 Puchong, Selangor dan secara iklan di akhbar tempatan.

[6] Pemohon telah memfailkan hujahan pada 13/12/2019, manakala Responden hanya memfailkan Afidavit Jawapan dan hujahannya pada 17/12/2019. Hujahan Tambahan Pemohon difailkan pada 30/12/2019. YA Hakim Bicara pada 13/1/2020, telah membuat keputusan terhadap permohonan tersebut sepertimana berikut -

- i. *Mahkamah tidak meluluskan permohonan Pemohon sebagaimana seksyen 201 ETMMS 2003.*
- ii. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak sementara bagi anak-anak yang bernama Muhammad Zidane Bin Mohd Razif (No. Mykid : 081112-06-1157), Iris Nadia Binti Mohd Razif (No. Mykid : 100118-08-0316) dan Muhammad Abdullah bin Mohd Razif (No. Mykid : 150713-10-2589) diberikan kepada Responden (ibu).*
- iii. *Pemohon (bapa) diberikan hak bermalam dengan anak-anak tersebut pada minggu kedua dan minggu keempat dengan mengambil anak-anak tersebut ditempatkan tinggal anak-anak tersebut bermula jam 8.00 malam hari Jumaat dan memulangkan semula anak-anak tersebut kepada Responden sebelum atau pada jam 6.00 petang hari Ahad.*
- iv. *Mahkamah memerintahkan pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan / atau Pihak Berkuasa yang berkaitan untuk memastikan perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik.*
- v. *Perintah sementara ini hendaklah berkuatkuasa serta merta sehingga ada perintah lain dikeluarkan atau sehingga kes induk hadhanah Saman No. 10200-028-0026-2019 diputuskan.*

[7] Akibat tidak berpuashati dengan perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[8] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[9] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[10] Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[11] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Permohonan No. : 10200-038-0027-2019. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.

[13] Merujuk kepada Afidavit Sokongan Pemohon, dalam **Alasan Pertama** permohonan semakan, Pemohon mendakwa bahawa perintah yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara adalah bercanggah dan bertentangan dengan prinsip keadilan, kebajikan dan kemaslahatan pihak-pihak dari segi Hukum Syarak dan Undang-Undang. Kami dapati Pemohon juga telah membangkitkan semula apa yang telah dinyatakan di dalam Afidavit Sokongannya bagi kes Permohonan Perintah Interim Hadhanah ke dalam permohonan semakan ini.

[14] Berhubung dengan perkara ini, kami percaya kesemua perkara yang dibangkitkan oleh Pemohon dan Responden di dalam kertas kausa masing-masing telah dinilai dan dipertimbangkan oleh YA Hakim Bicara. Perkara ini dapat dilihat kenyataan YA Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakiman ringkasnya yang menyatakan –

“Mahkamah setelah berpuashati dengan Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden”

[15] Sukacita kami nyatakan bahawa prosiding Permohonan Perintah Interim Hadhanah ini adalah berbeza dengan prosiding kes induk hadhanah, di mana dalam prosiding interim hadhanah, YA Hakim Bicara hanya menilai dan mempertimbangkan berdasarkan kertas kausa yang dikemukakan tanpa berpeluang untuk mendengar keterangan pihak-pihak secara menyeluruh serta membuat penilaian terhadap pembuktian yang dikemukakan sepertimana kes induk hadhanah.

[16] Merujuk kepada perintah YA Hakim Bicara bertarikh 13/1/2020, kami dapati perintah tersebut tidak wujud sebarang prinsip yang menghalang keadilan, kebajikan dan kemaslahatan terhadap anak-anak tersebut, di mana perintah tersebut telah menentukan Penjaga kepada anak-anak tersebut serta hak lawatan dan bersama dengan anak-anak tersebut diberikan bagi pihak yang tidak mendapat hak penjagaan tersebut.

[17] Bagi kes hadhanah ini, kemaslahatan terhadap anak-anak tersebut yang lebih diutamakan berbanding kemaslahatan pihak-pihak. Ini telah dijelaskan di dalam kitab *Fiqh As-Sunnah* yang menyatakan -

إن لكل من الحضانة والمحضون حقاً في الحضانة, إلا أن حق المحضون أقوى من الحضانة

Bermaksud : “Sesungguhnya setiap penjaga dan anak jagaan masing-masing mempunyai hak. Akan tetapi hak anak atau kemaslahatan anak lebih penting dari hak penjaganya”

[18] Perkara yang sama juga telah diulas oleh Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan di dalam kes *Mohd Radhi bin Haji Che Daud lwn Khadijah binti Yaacob[2004] JH 17(1)* iaitu -

“Tujuan hadhanah atau penjagaan kanak-kanak ialah untuk masalah dan kebaikan kanak-kanak yang dipelihara sebagai hak asasi bagi kanak-kanak itu dan hak itu mesti diutamakan lebih dari hak pihak yang ingin memelihara mereka.”

[19] Oleh yang yang demikian, kami berpuashati menyatakan bahawa soal kemaslahatan anak-anak tersebut adalah lebih utama berbanding dengan kemaslahatan pihak-pihak dan YA Hakim Bicara telah menilai dan mempertimbangkan perkara tersebut sebelum keputusan tersebut dibuat. Kami berpuashati pertimbangan isu kemaslahatan ini telah dipertimbangkan oleh YA Hakim Bicara sebelum keputusan diberikan pada 13/1/2020.

[20] Bagi **Alasan Kedua**, Pemohon menyatakan bahawa wujudnya kecacatan dalam proses / prosedur Mahkamah Bicara. Pemohon menyatakan bahawa –

- i. Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menilai elemen keterdesakan (*urgency*) dalam Permohonan Interim Hadhanah tersebut. Rentetan itu, permohonan tersebut didengar secara inter-parte, namun pihak Responden gagal hadir pada awalnya;
- ii. Hakim Bicara tidak terus memutuskan permohonan tersebut, sebaliknya mengarahkan untuk mendengar permohonan tersebut dengan kes induk tuntutan hadhanah;
- iii. Pada 19/11/2019, Responden telah hadir dan gagal mematuhi tarikh-tarikh pemfailan yang ditetapkan oleh Hakim Bicara tersebut; dan
- iv. Hakim Bicara terus memutuskan Perintah Interim Hadhanah tersebut tanpa mengambil kira prosedur / tatacara yang betul dengan sewajarnya.

[21] Berhubung dengan alasan ini, melalui penelitian yang telah dijalankan, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara telah mengikuti prosedur / tatacara ketika mengendalikan Permohonan Perintah Interim Hadhanah Pemohon yang difailkan secara ex-parte tanpa mempunyai alasan yang mendesak (*urgency*). Kami juga berpuashati bahawa penyampaian kertas kausa kes tersebut telah gagal disempurnakan secara kediri, sebaliknya disempurnakan melalui penyampaian gantian secara tampalan (pada 4/3/2019) dan iklan (pada 18/3/2019). Responden hanya hadir ketika sebutan bertarikh 11/19/2019 dan telah memfailkan Afidavit Jawapan dan hujahannya pada 17/12/2019. Keputusan Permohonan Interim Hadhanah tersebut telah diputuskan pada 13/1/2020.

[22] Melalui penelitian yang dibuat dari kenyataan Pemohon di dalam Afidavit Sokongannya, kami berpuashati menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah memenuhi prosedur / tatacara dalam mengendalikan prosiding kes interim tersebut. Walaubagaimanapun melalui penelitian yang dijalankan, kami dapati status anak-anak yang menjadi '*subjek matter*' di dalam kes interim tersebut iaitu anak pertama dan kedua telah mencapai umur mumaiyiz, manakala anak ketiga masih lagi belum mumaiyiz.

[1] Bagi anak yang belum mumaiyiz, maka ia adalah tertakluk kepada '*status quo*' undang-undang berdasarkan seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003] di mana ibu adalah pihak yang paling berhak terhadap hak penjagaan anak kecil (belum mumaiyiz) dan hak ini diberikan kepada ibu tersebut apabila ia memenuhi syarat kelayakan sepertimana yang dinyatakan pada peruntukan seksyen 83 EUUKIS 2003. *Status quo* ini juga telah diulas oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor sebagai anggapan undang-undang di dalam kes ***Abdul Malek Bin Abdul Kadir lwn. Zulzilawati Binti Jusoh, Kes Rayuan (Selangor) No. : 10000-028-0084-2016*** sepertimana berikut -

"Anggapan ini telah memberikan kedudukan yang positif kepada Responden sebagai ibu kepada anak tersebut. Namun demikian anggapan ini boleh dipatahkan jika isu ketidaklayakan seseorang penjaga dibawah seksyen 84 dapat dibuktikan. Dalam hal ini, Perayu sebagai Defendan telah mempertikaikan kelayakan Responden sebagai Penjaga dalam pembelaannya. Oleh itu beban tersebut perlulah ditanggung oleh Perayu berdasarkan seksyen 73 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Selangor 2003..."

[23] Merujuk kepada Alasan Penghakiman Ringkas YA Hakim Bicara, kami dapati bahawa telah membuat sabitan bahawa Responden tidak hilang kelayakan sepertimana peruntukan seksyen 84 EUUKIS 2003. Oleh yang demikian penghakiman YA Hakim Bicara terhadap Anak Ketiga tersebut yang belum mumaiyiz adalah menepati kehendak undang-undang dan Hukum Syarak.

[24] Manakala bagi anak-anak yang telah mumaiyiz, penentuan hak jagaan dibuat setelah anak-anak tersebut dipanggil untuk membuat pilihan dengan siapa anak-anak tersebut ingin tinggal. Hak mereka membuat pilihan telah jelas diperuntukkan dalam seksyen 85 (2) EUUKIS yang menyatakan -

"Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya"

[25] Bagi kes ini, kami dapati Hakim Bicara telah membuat keputusan tanpa memanggil Anak Pertama (umur 12 tahun) dan Anak Kedua (umur 9 tahun) yang telah mumaiyiz untuk membuat pilihan sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang tersebut. Selain daripada itu, kami juga telah merujuk kepada Alasan Penghakiman Ringkas YA Hakim Bicara dan kami dapati bahawa YA Hakim Bicara telah tidak memberikan apa-apa alasan atau justifikasi apabila tidak memanggil dan mendengar pilihan anak-anak yang telah mumaiyiz tersebut sebagaimana yang telah digariskan oleh Hukum Syarak dan undang-undang.

[26] Berdasarkan kepada ulasan kami di atas, maka kami bersetuju bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf sehingga boleh menjejaskan keadilan kepada pihak-

pihak apabila membuat keputusan tanpa memberikan apa-apa alasan atau justifikasi serta tidak merujuk kepada mana-mana peruntukan yang berkaitan. Kami berpendapat bahawa telah berlaku kesilapan dan kecacatan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak. Oleh yang demikian, adalah wajar untuk kami campur tangan terhadap Perintah Hak Jagaan Sementara yang dikeluarkan bertarikh 13/1/2020 tersebut.

[27] Demi kebajikan anak-anak tersebut juga, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk hadhanah perlulah disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini seboleh-bolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk.

[28] Pada kesempatan ini, sukacita kami mengingatkan kepada kedua-dua pihak agar mematuhi apa-apa perintah / penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah tanpa engkar agar proses perlaksanaan perintah / penghakiman Mahkamah berjalan lancar. Mahkamah juga menasihatkan kepada Perayu dan Responden sebagai ibubapa kepada anak-anak tersebut, agar memberi kerjasama dalam memastikan kebajikan dan kemaslahatan anak tersebut terjaga tanpa halangan antara satu sama lain bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai ibu dan bapa kepada anak tersebut. Hargailah kurniaan anak kepada kita kerana ia adalah **AMANAH ALLAH** s.w.t. yang tidak ternilai.

KEPUTUSAN

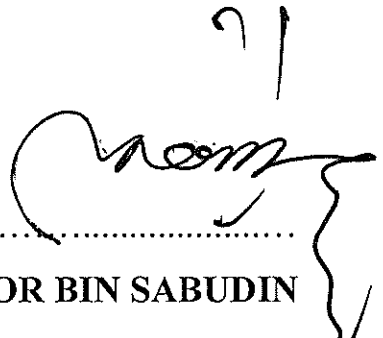
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Affidavit Permohonan Pemohon dan fail kes yang disemak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.

- [2] **Terma 3 dan 4** Perintah Interim Hadhanah bagi Kes Permohonan No. : 10200-038-0027-2019 bertarikh 13/1/2020 terhadap **Anak Pertama** dan **Anak Kedua** adalah **DIBATALKAN**. Manakala **terma 3 dan 4** bagi **Anak Ketiga** adalah **DIKEKALKAN**.

- [3] Prosiding Kes Permohonan No. : 10200-038-0027-2019 hendaklah diteruskan pendengaran semula dengan memanggil Anak Pertama dan Kedua untuk membuat pilihan sebelum pertimbangan terhadap keputusan dibuat.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

- 
.....
- 1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor